



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/64/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט-שילוני

1	סגל אביאל, ת.ז. 054669874 העפרוני 5/29, אילת	תובעים
2	ברון ילנה, ת.ז. 311700421 העפרוני 5/3, אילת	
נגד		
	יוסף אסף, ת.ז. 33291808 העפרוני 5/1, אילת	נתבע

פסק דין

רקע והשתלשלות ההליך

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב העפרוני 5, אילת המצוי במקרקעין בגוש 40005 חלקה 90. המדובר בפרויקט מגורים חדש שנבנה בין השנים 2014-2016 על-ידי חברת רד סי הייטס בע"מ וחברת הרי אילת הנדסה בניין ופיתוח בע"מ (להלן – **הקבלן**) ואשר טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים (להלן – **הבית המשותף** או **הבית**). על פי כתב התביעה, התובע 1 הוא בעל הזכויות בדירה מספר 29 בבית המשותף (יצוין כי התובע 1 מכהן כיו"ר נציגות הבית המשותף אך תביעה זו הוגשה בכובעו כבעל דירה פרטי), התובעת 2 היא בעלת הזכויות בדירה מספר 3 והנתבע הוא בעל הזכויות בדירה מספר 1 אשר הינה דירת גן הממוקמת בחזית הבית ומתחת לדירת התובעת 2. התביעה היא למתן צו עשה אשר יורה לנתבע להסיר פרגולה שהתקין בחצר הצמודה לדירתו תוך עיגונה לקירות החיצוניים של הבית שיש בה, לפי הנתען, כדי לפגוע במראה החיצוני של הבית ובערכן של הדירות, והיא מהווה מטרד עבור התובעת 2.

טענות הצדדים

2. לטענת התובעים, בניית הפרגולה נעשתה בניגוד לתקנון הבית המשותף. לכתב התביעה צירפו התובעים מסמך שכותרתו "תקנון ניהול הבית המשותף רד סי הייטס" במסגרתו נקבע בין היתר כי: "**חל איסור לבצע שינויים חיצוניים בקירות הפרויקט (קרי, התקנת מזגנים או מתקנים אחרים כל שהם בקירות חוץ, פתיחת פתחים או קדיחת חורים בקירות**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/64/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

החוץ, התקנת תריסים, בניית פרגולות, התקנת סורגים, התקנת צינורות וכל חומר אחר על הקירות החיצוניים, הצללות מכל מין וסוג שהוא וכיו"ב), דבר הפוגע מהותית באחידות המראה החיצוני של הפרויקט ומהווה מטרד לכל הדיירים ופגיעה ברכושם. לעמדת התובעים, על פי התקנון חל איסור מפורש לבצע שינויים בקירות הבית המשותף לרבות בניית פרגולות. המסמך הנ"ל נוסח על ידי הקבלן והוא מהווה תקנון מוסכם הגם שהבית כלל לא נרשם כבית משותף וזאת כיוון שכל בעלי הדירות הסכימו על כינונו במסגרת הסכמי המכר מול הקבלן ובמעמד קבלת החזקה בדירות. כדי לאשש טענתם זו הציגו התובעים חמישה פרוטוקולי מסירת דירה של בעלי דירות בבית המשותף אליהם צורף הסעיף האמור בעניין איסור ביצוע שינויים ברכוש המשותף והם נושאים את חתימותיהם של אותם בעלי דירות. התובעים ציינו, כי מאז אכלוס הבית מקפידים בעלי הדירות לשמור על הכללים שנקבעו בתקנון, ואולם בעקבות הפרתם בידי הנתבע מסתמן כי בעלי דירות נוספים מבקשים אף הם להתקין במרפסת דירתם מתקני הצללה שעשויים לפגוע במראה החיצוני האחיד של הבית. לשיטת התובעים, הפרגולה משתרעת על כל שטח חצרו של הנתבע מהקיר החיצוני של הבית המשותף ועד קו המדרכה ברחוב והיא ממוקמת על גבי הקיר החיצוני בגובה רצפת מרפסת דירת התובעת 2. התובעים צירפו תמונות הממחישות את גודל הפרגולה ומיקומה. התובעים טענו כי בניית הפרגולה תוך עיגונה לקירות החיצוניים של הבית מהווה שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף שלא ניתנה לגביו הסכמת האסיפה הכללית, פוגעת בערכן של הדירות ומסבה לתובעת 2 חוסר נוחות. לעניין זה נטען, כי מאז התקנת הפרגולה גובר אצל התובעת 2 החשש מפני פריצה לדירתה דרך המרפסת ונחסם חלק ניכר מהנוף הנשקף ממנה. כן נטען, כי בגג הפרגולה נערמת צואת בעלי חיים העולה כדי מפגע תברואתי. בהקשר זה מפנים התובעים להוראות סעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן – **התקנון המצוי**) בציינם כי זכות הבעלות במקרקעין אינה מצדיקה גרימת נזק או אי נוחות לאחר.

3. מנגד טען הנתבע כי מאחר שהפרגולה נבנתה בחצר ביתו הפרטית וברכושו הפרטי אין כל עילה להסרתה. בתוך כך טען הנתבע, כי אין מדובר בשימוש ברכוש משותף שכן כל נקודות העגינה של הפרגולה, לרבות בחלקה העליון, מצויות בתחומי דירתו ולא בחלקי הרכוש המשותף. על כך הוסיף הנתבע לטעון, כי הפרגולה אינה פוגעת במראהו החיצוני של הבית כמו גם אין בה כדי לפגוע בערכן של הדירות או כדי להוות מטרד עבור התובעת 2. הנתבע הבהיר, כי הפרגולה נועדה להגן מפני פגיעת חפצים שנזרקים מהקומות העליונות לעבר חצר ביתו, וכן לשם שמירה על פרטיותו והגנה מפני השמש. לדבריו, בידו להשיג הסכמתם של 90% מבעלי הדירות הרבה מעל לרוב הדרוש. אשר למסמך שנערך בידי הקבלן טען הנתבע כי תקנון זה אינו קובע כללים לגבי שימוש ברכוש הפרטי ואילו התקנת הפרגולה נעשתה במסגרת רכושו הפרטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/64/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה

4. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ועיינתי בחומר הראיתי שהונח לפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל. להלן טעמי.
5. כמפורט לעיל, הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים ולפיכך חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, לרבות הוראת סעיף 77ג הקובעת כי בית כאמור יתנהל לפי התקנון המצוי.
6. איני מוצאת לנכון לקבל את הטענה כי למסמך שערך הקבלן יש מעמד של תקנון מוסכם כשיטת התובעים. אמנם הוכח בפניי, כי במסגרת הסכמי המכר הוסכם כי הקבלן יקבע תקנון אשר יסדיר את היחסים בין בעלי הדירות בכל הנוגע לחובותיהם וזכויותיהם בבית המשותף, אלא שמן התצהיר שמסר הקבלן בהתאם להחלטתי מיום 9.7.19 עולה כי המסמך שנטען לגביו כי הוא מהווה תקנון מוסכם אינו אלא המלצה להוראות וכללי ניקיון, ובנוסף, לא חתמו עליו כל בעלי הדירות בבית המשותף אלא רק מרביתם. לפיכך יחולו על נסיבות העניין הוראות התקנון המצוי בלבד.
7. רכוש משותף מוגדר בסעיף 77א לחוק המקרקעין כך:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת." (ההדגשה אינה במקור).
8. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע כי:

2. (א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזונו החיצוני התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו." (ההדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/64/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. מכוחה של הוראת דין זו, חל איסור על בעלים של דירה בבית משותף לבצע שינויים או תיקונים בדירתו הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או בעל הדירה האחרת לפי העניין.

10. על טיבה של הפגיעה על-פי סעיף 2 לתקנון המצוי עמד בית המשפט העליון הנכבד כבר בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו, 20.05.66) בקבעו כי:

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית - כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל."

11. ברוח דברים אלה נקבע, כי פגיעה במובנה על-פי סעיף 2 לתקנון המצוי יכול שתהא מכל סוג שהוא, ואין נפקא מינא אם גדולה או קטנה היא, אם היא ניתנת לפיצוי אם לאו:

"כאן עלי לתקן טעות שנפלה כנראה בהיסח הדעת בפסק דינו של בית המשפט המחוזי. הוא אמר כי הפגיעה שמדובר בה בסעיף הנדון צריכה להיות בשיעור כזה שהיא עשויה לסכן את הקיום או לשנות את ערך הבית או הדירה; ולא היא. קריאה נכונה של הסעיף הנדון מראה שפגיעה מכל סוג שהוא בדירה אחרת או ברכוש המשותף אסור שתבוא עקב שינויים או תיקונים הנעשים בדירה אחת. ...אמרנו שאין נפקא מינא אם הפגיעה קטנה או גדולה וניתנת לפיצוי נאות או לא...המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם (מ"מ הנשיא בפסק-דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, [3], הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית- המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם." (ע"א 395/74 יצחק לוי נ' רבקה סמואל (פורסם בנבו, 13.03.75)) (ההדגשות אינן במקור).

12. בענייננו, אין חולק כי התקנת הפרגולה בחצר ביתו של הנתבע מהווה שינוי במובנו על פי סעיף 2 לתקנון המצוי (למשמעות המונח שינוי ראה: ד"נ 20/73 יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי (פורסם בנבו, 10.03.74)) (להלן – עניין שמע).

13. עיון בתמונות שצורפו לכתב התביעה ולסיכומי התובעים מעלה, כי הפרגולה הותקנה על גבי ולאורכו של קיר הבית המשותף המהווה רכוש משותף (ראה עמוד 16 לכתב התביעה). כך עולה, כי הקורות המרכיבות את גג הפרגולה יוצאות מקווי הבנין באופן שבו מגיעות עד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/64/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קו המדרכה הסמוך לכביש. כן עולה מהתמונות כי הפרגולה ממשיכה בעצם את קו מרפסת דירתה של התובעת 2.
כל זאת כפי שניתן לראות מהתמונות הבאות:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/64/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עוד עולה מהתמונות, כי המדובר אכן בבית חדש שמראהו החיצוני אחיד וחזיתו נקייה מכל בנייה או תוספת מתקני הצללה (למעט דירה אחת – ראה עמוד 13 לכתב התביעה). בנסיבות אלה, סבורני כי יש ממש בטענות התובעים כי אין מדובר בפגיעה של מה בכך וכי היה על הנתבע לקבל הסכמת האסיפה הכללית לצורך כך ואף הסכמת התובעת 2.

14. אלא שהנחת המוצא מצדו של הנתבע היתה כי בניית הפרגולה נעשתה ברכושו הפרטי ועל כן לא נזקק לאישור איש ולא עומדת לתובעים זכות להתנגד לכך. הנחה זו בטעות יסודה. ראשית, הפרגולה מותקנת על גבי קירות הבית המשותף המהווים רכוש משותף. שנית, זכות הבעלות ביחידות הדירור בבית משותף אין היא כזכות הבעלות הקלאסית. זכות זו מוגבלת בזכויות הבעלים בדירות האחרות וברכוש המשותף (עניין שמע). יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון הנכבד ברע"א 1462/10 עטייה נ' שגיא (פורסם בנבו, 02.08.12) על ייחודן של הזכויות הקנייניות במוסד הבית המשותף:

"התפישה היא שזכויות הקניין בבית המשותף עוצבו מלכתחילה באורח שונה מזה של זכות בעלות במובן ה"קלאסי" (שהוגדרה כזכותו של אדם לעשות ולא לעשות בקניינו כרצונו), כך שבעלי הדירות מוותרים על חלק מהאוטונומיה הקניינית הקנויה להם ומקנים חלק מזכויותיהם למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה. דפוס זה מצר את תוכנה של זכות הקניין הנפרדת ברכוש המשותף כדי להתאימה לתכונות הייחודיות של הבית המשותף. כך, בנסיבות מסוימות ניתן להגביל את יכולתו של המיעוט לכפות את רצונו על הרוב, גם אם משמעות הדבר היא פגיעה בזכויותיו הקנייניות של המיעוט ברכוש המשותף."

15. יודגש, כי חרף הצהרותיו של הנתבע בכתב ההגנה ובמהלך הדיון המקדמי כי יש בידו להשיג הסכמתם של 90% מבעלי הדירות בדיעבד, הרי שלא הובאה כל הוכחה לכך. הלכה פסוקה היא כי מעמידים בעל-דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראייה שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו (ראה ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני (פורסם בנבו, 16.12.80)).

16. אשר על כן, מסקנתי היא שהפרגולה במתכונתה הנוכחית, בגודלה העצום הגולש אל מעבר לקווי הבנין ובמיקומה כך שהיא מהווה המשך ישיר של דירת התובעת 2 מבלי שנתקבלה הסכמת האסיפה הכללית והסכמת התובעת, אינה יכולה להיות על כנה. למען הזהירות אבהיר כי התקנת פרגולה בדירת גן, כשלעצמה, אינה מהווה תמיד פגיעה מן הסוג המובא בסעיף 2 לתקנון הבית המשותף. מדובר בצורך הולך וגובר נוכח האקלים המתחמם, ואפשר שמסקנתי היתה שונה אלמלא הפגיעה הניכרת בחזותו החיצונית של הבית בנסיבות המקרה דנן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/64/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

17. למעלה מן הצורך אציין, כי הטענה למטרד שנגרם בעקבות התקנת הפרגולה אינה מצויה במסגרת סמכותי כמפקחת על רישום מקרקעין (סעיף 72 לחוק המקרקעין; עניין שמע). כמו כן, טענות התובעים בדבר פגיעה בערכן של הדירות נטענו באופן כללי וללא כל ביסוס, ואין בידי לקבלן כאילו די בהעלאת טענות ערטילאיות כדי לבסס ירידת ערך בנסיבות העניין.

סוף דבר

18. התביעה מתקבלת. הנתבע יסיר את הפרגולה בתוך 30 יום.
19. לאור התוצאה אליה הגעתי אני קובעת כי הנתבע יישא בהוצאות התובעים בסך של 2,000 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין עד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 6 בנובמבר 2019, ח' חשון תש"פ, בהיעדר הצדדים.

**ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין**